

1500276-29.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... como a região é conhecida como ponto de tráfico, foram averiguar. Viram o réu mexendo numa pochete e depois a deixando no muro. Abordado, na pochete estavam o dinheiro e as drogas, tendo ele confessou que estava no trafico de drogas e que o dinheiro era das vendas de drogas. Reconhece o réu e não o viu no local antes.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-29.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000176

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033926/2022 - 03º D.P. DIADEMA, 2033926 - 03º D.P. DIADEMA, 445/22/127 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Wanderson de Souza Rodrigues

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ROGÉRIO WENDERSON DE SOUZA RODRIGUES, qualificado às fls. 10 e 12/13, está sendo processado no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 15h40, na Avenida Presidente Costa e Silva, altura do nº 300, Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 119 embalagens plásticas contendo 153g da droga cocaína, 52 embalagens plásticas contendo 45,58g da mesma droga, na forma de crack, e 128 embalagens plásticas contendo 405,7g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 21/22 e laudo de constatação provisória de fls. 27/29, agindo sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 49/52), e denegada ordem de HC. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 13/06/2022 (fl.137) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu (fls.96 e 151/152).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade de drogas, com a atenuante da confissão, concordando com a redução da pena, mas em patamar mínimo, sem a substituição pela pena corporal pela restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, mais a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal dada à primariedade do acusado, com a redução pela atenuante da confissão, e o redutor máximo da pena ainda por ser tráfico privilegiado, além da substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade ante a detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.21/22, nos autos de constatação e no definitivo (fls. 27/29 e 97/99), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.07/09), realizavam patrulhamento pela região dos fatos, quando, ao passarem pela avenida Presidente Costa e Silva, altura do numeral 300, avistaram um indivíduo revirando uma pochete, aparentemente tentando esconder alguma coisa, que ao avistar os patrulheiros, demonstrou nervosismo e tentou se evadir, motivando a abordagem. Capturado logo em seguida, foi realizada a busca pessoal no indivíduo agora qualificado como Rogério Wenderson De Souza Rodrigues, sendo que na pochete que portava se encontravam 128 invólucros de substância semelhante à maconha, 119 invólucros de substância semelhante à cocaína e 52 invólucros de substância semelhante à crack, além de da importância de R\$119,00. Indagado pelos militares sobre as substâncias com ele encontradas, Rogério confessou que estava no local vendendo os entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório o policial Lucas Dan reiterou que estavam em patrulhamento e como a região é conhecida como ponto de tráfico, foram averiguar. Viram o réu mexendo numa pochete e depois a deixando no muro. Abordado, na pochete estavam o dinheiro e as drogas, tendo ele confessado que estava no tráfico de drogas e que o dinheiro era das vendas de drogas. Reconhece o réu e não o viu no local antes.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Wellisson Francez, confirmou que em patrulhamento pela região que já é um ponto de venda de drogas conhecido. Visualizou o réu mexendo numa pochete perto de um arbusto. Encostaram próximo a ele a pochete. Ele tentou se esquivar, mas foi abordado, e com ele estavam as drogas e certa quantia em dinheiro. O acusado informalmente confessou o tráfico de drogas e que o dinheiro era da venda delas. Reconhece o réu e não o viu no local antes.

O réu, em solo policial (fl.10) confessou que estava vendendo as drogas, mas não reconhece a totalidade das substâncias apresentadas por eles, nem a totalidade da importância em dinheiro, uma vez que estava apenas com 100 reais na pochete.

Em juízo o acusado alegou que estava no ponto de venda de drogas e foi enquadrado. Tentou correr, mas foi alcançado. Estava há pouco tempo no tráfico porque não arrumava serviço, e que é usuário de drogas. Começou no dia anterior a vender, e o dinheiro apreendido era da venda das drogas. Já foi processado por assalto.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Não bastasse isso, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Isso porque: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Assim como não procede a tese de se tratar de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. E também afasto tese de situação de pobreza ou desemprego, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato, além de não haver provas nos autos de que o réu passasse por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (R\$119,00), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo

peçoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas sim a grande quantidade do narcótico apreendido (199 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal: 05 anos e 08 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e sim a atenuante da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fl.30), mas considerando a apreensão dinheiro proveniente de efetivas vendas de drogas a usuários, disseminando e contribuindo com o vício, e pela natureza de maior parte das drogas, cocaína e crack, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, entendo que o redutor de ½ é o razoável e proporcional à maior dedicação do réu à traficância ilícita, pois segundo ele, já era seu segundo dia trabalhando na mercancia ilícita de narcóticos, totalizando assim 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena e primariedade do agente, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não fixando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para

autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, tratando-se de réu já condenado por assalto, a indicar envolvimento criminal prévio, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ademais (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ROGÉRIO WENDERSON DE SOUZA RODRIGUES, qualificado às fls. 10 e 12/13, pela prática do crime tipificado no

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sendo ele beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl.21 e 67), com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA